

1501978-75.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GABRIEL MAZZUCATO COSTA

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

JOÃO GABRIEL MAZZUCATO COSTA, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de dezembro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1501978-75.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501978-75.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GABRIEL MAZZUCATO COSTA

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

JOÃO GABRIEL MAZZUCATO COSTA, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 09h10, na Rua Doutor José Milton de Freitas, 100, Jardim Valkiria, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, foi surpreendido por policiais civis mantendo em depósito, com o fim de posterior venda a terceiros consumidores, 54,93g de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, e um microponeto de LSD, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo.

Segundo a denúncia, existiam denúncias de que o acusado vendia drogas pela internet, por intermédio das redes sociais. Diante disso, foi expedido mandado de

busca e apreensão, que foi cumprido pela polícia civil no dia 28 de dezembro de 2021. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, na cozinha do apartamento, os dois sacos plásticos contendo porções de maconha e um rolo de plástico filme usado para embalar a droga. Além disso, na sala, encontraram uma vasilha de alumínio contendo diversas porções de maconha, uma balança de precisão, uma porção de LSD e R\$ 17,00 em dinheiro.

Continuando as buscas os policiais localizaram, no único quarto do imóvel, um espectro de luz comumente utilizado para acelerar o crescimento de plantação de maconha "indoor". Dentre do carro de João Gabriel, que se encontrava estacionado na garagem do prédio, encontraram vários vasos, material de estufa de plantação "indoor" e um invólucro plástico de adubo de plantas. Em conversa informal com os investigadores de polícia o acusado afirmou que vendia cada porção de maconha a R\$ 40,00 e dava consultorias a respeito de plantio e cultivo de maconha indoor para outros traficantes, além de alugar o equipamento.

O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 01/07), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 55/56.

Notificado (págs. 157/158), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 175/211).

A denúncia foi recebida (págs. 229/230) e o acusado regularmente citado (págs. 249).

Folha de Antecedentes a págs. 36/40 e certidão de eventos a págs. 33/35.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas comuns, sendo o acusado interrogado (págs. 281/285).

Em Memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º e artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072 de 1990, (págs. 286/292).

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, com fixação da pena no mínimo legal, e regime inicial aberto, nos termos do art. 59 do CP, e direito de apelar em liberdade (págs. 296/326).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade dos delitos restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 14/16, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 18/19 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado a págs. 102/104 e 105/108, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional. Observo que no laudo de págs. 160/162 relativo ao microponto aparentemente de LSD, não foi possível identificar presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98.

Quanto à autoria dúvidas não há.

Os policiais civis foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que o acusado estava sendo investigado por comercializar drogas pela internet. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram apreendidos dois sacos plásticos com porções de maconha, um rolo de papel filme usado para embalar pequenas porções da droga, uma vasilha de alumínio contendo diversas porções da mesma droga, uma balança de precisão, R\$17,00 em dinheiro, e espectro de luz usado para acelerar o crescimento da plantação "indoor" de maconha. No carro de João Gabriel, os depoentes localizaram vários vasos, material de estufa de plantação "indoor", além de um invólucro plástico de adubo de plantas. Indagado, o acusado confessou-lhes que vendia drogas pela internet. Quanto ao material destinado à estufa, João afirmou que tinha uma plantação, mas a desativou, cujo material, atualmente, estava alugando para outros traficantes. O réu esclareceu-lhes, ainda, que prestava consultoria pela internet, através de vídeos e pessoalmente, ajudando outras pessoas a plantar e cultivar maconha.

Em juízo, ao ser questionada pela Defesa, a testemunha Eduardo afirmou que após denúncias dando conta do tráfico realizado pelo réu, foram realizadas algumas campanhas defronte ao imóvel do acusado, sendo possível notar movimentação de pessoas, as quais faziam apologia a entorpecentes nas redes sociais. A testemunha

confirmou que foram encontrados no apartamento do réu drogas, balança de precisão, material de embalar o entorpecente e dinheiro. Aduziu que não foi realizada perícia no imóvel, por falta de pertinência. Esclareceu que o réu foi informado sobre o direito de permanecer em silêncio e, ainda assim, ele se mostrou prestativo e colaborativo com a polícia, sendo que, a todo tempo, confessou os fatos, desbloqueou seu aparelho celular e lhe mostrou mensagens e aplicativos utilizados para este fim que o depoente sequer conhecia. Sobre a venda on-line, o policial viu mensagens em seu celular.

A testemunha Humberto confirmou que na residência do acusado foram encontradas drogas, balança de precisão, estufa e equipamento que fazia a função de luz solar utilizado no cultivo de plantas. O acusado lhe confessou que vendia drogas pela internet, prestava consultoria a outras pessoas que plantavam "maconha" e recebia mensalmente por isso. Acrescentou que não conhecia o acusado e ele se mostrou muito receptivo com a polícia. O réu lhe informou que fazia uso de drogas, e também comercializava entorpecentes. A testemunha esclareceu que o droga localizada estava fracionado, o que é comum para a "maconha gourmet", já que ela não pode ser prensada.

Interrogado na fase policial, o acusado negou a traficância, dizendo que é usuário de drogas e que o entorpecente apreendido em sua residência destinava-se ao seu uso pessoal. Sobre os apetrechos encontrados em seu carro, afirmou que há alguns anos mantinha uma estufa para plantação "indoor" de maconha, mas a desativou, por isso estava tentando vender este equipamento. Os policiais encontraram o seu aparelho celular diversas conversas nas quais ele orientava pessoas a cultivar maconha, esclarecendo que não angariava qualquer valor para orientar o plantio da droga. Em juízo, o acusado afirmou que é usuário de "maconha" e paciente medicinal. Disse que os acessórios de cultivo apreendidos em seu carro estavam inutilizados desde a primeira vez que os policiais invadiram sua casa e os desmontaram, aduzindo que pretendia vender tais equipamentos, negando que os alugava. Confirmou que participava de vários grupos de cultivo e produção de maconha e óleos e, mesmo após sua primeira prisão, continuou participando destes grupos. Disse que, por ser muito estudioso, muitas pessoas lhe procuravam buscando informação de como se tornar um paciente medicinal, aduzindo que prestava consultoria a elas.

Indagado pela Defesa, o acusado disse que é usuário de entorpecente desde a adolescente, e há alguns anos começou fazer tratamento médico com o uso de "maconha". Disse que participava de eventos e associações relacionadas à cannabis, em prol da descriminalização da planta e do medicamento. Tem ciência que a droga ainda não é legalizada no Brasil. Disse que fazia extrato de maconha para misturar no azeite. Afirmou que a quantidade de droga apreendida em sua residência seria suficiente para fazer 54 cigarros, os quais seriam utilizados em 8 dias. Esclareceu que desbloqueou seu celular, após insistência dos policiais, aduzindo que as conversas lá havidas eram de consultoria sobre o uso medicinal da droga. Disse que não foi advertido, em nenhum momento, sobre seu direito ao silêncio. Afirmou que, mesmo sabendo dos riscos, optou por cultivar "maconha", a fim de evitar ir às ruas e procurar alguém para comprá-la. Negou o tráfico de drogas, mas confirmou que cometeu um crime, aduzindo que é estudante do 10º semestre de direito e tem consciência que o uso de maconha ainda não é legalizado.

Ao que se vê, a versão apresentada pelo acusado está isolada da demais provas dos autos.

Os policiais apresentaram versões uníssonas em ambas as fases do processo, descrevendo que, a partir de denúncias de tráfico de drogas, passaram a investigar o acusado, sendo representada pela busca domiciliar. Em cumprimento ao mandado, localizaram na residência do acusado drogas, dinheiro, balança de precisão, material para embalagem, além de petrechos destinados ao cultivo de plantas. O acusado confessou-lhes que vendia drogas, prestava consultoria e locava os equipamentos para cultivo de "maconha".

Observo que inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se

pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). O acusado, por sua vez, alega que é usuário medicinal de "maconha", que fazia azeite com o entorpecente e prestava consultoria para outras pessoas que tinham interesse em se tornar pacientes medicinais. Aduziu que iria se desfazer dos equipamentos apreendidos, os quais eram utilizados para o cultivo de "maconha", mas estavam desativados. Afirmou que é estudante de direito, e tem ciência que a "maconha" ainda não é legalizada no Brasil.

Observo que, apesar do acusado não confessar os fatos de forma cabal, ele admite que cultivava "maconha", para evitar sair nas ruas para comprar, e produzia azeite com esta droga, aduzindo ser tudo para seu uso próprio.

Ocorre que os policiais confirmaram que havia denúncias dando conta do tráfico de drogas praticado pelo réu, sendo em sua residência apreendidas "maconha", balança de precisão (com resquícios de drogas conforme laudo de pág. 105/108), material para embalar o entorpecente, além de petrechos destinados ao cultivo da droga. Não bastasse, o acusado forneceu detalhes de sua conduta criminoso aos policiais, aduzindo que vendia "maconha gourmet", prestava consultoria para outros traficantes e locava os equipamentos para cultivo da droga, além de ser também usuário. Os policiais confirmaram que no celular do acusado havia diversas conversas sobre venda e informações de drogas, já o acusado afirmou que participava de inúmeros grupos e trocava informações sobre a produção e a legalização da droga.

Sobre o material de estufa de plantação "indoor", o acusado confirmou que lhe pertencia e estava em seu carro, pois iria vendê-lo, o qual fora desativado pelos policiais quando de sua primeira prisão em flagrante.

Observo que o acusado foi preso, por primeiro, no dia 29 de janeiro de 2020, por tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidos em sua residência equipamentos destinados ao cultivo da planta. Observo também que tais objetos ficaram apreendidos nos autos 1500172-39.2020.8.26.0559 (5ª Vara Criminal).

Ou seja, a alegação de João de que estava se desfazendo de tais objetos, praticamente dois anos após sua primeira prisão em flagrante, não deve prosperar. Em verdade, o acusado mantinha esses equipamentos em seu carro, pois, conforme ele próprio afirmou aos policiais, locava tais materiais para que outros traficantes pudessem cultivar "maconha". Assim, perfeitamente caracterizado também o crime previsto no art. 34 da Lei de Drogas.

No que atine à alegação da Defesa de que o réu não fora cientificado sobre seu direito constitucional ao silêncio, observo que os policiais confirmaram que, mesmo após adverti-lo, o acusado se mostrou prestativo e colaborou com as investigações. Por outro lado, João responde a outro processo por tráfico de droga, além de já ter sido condenado no ano de 2007 por porte ilegal de arma de fogo, para além de ser estudante do 10º semestre de direito. Assim, descabida a alegação de que desconhecida seu direito de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo.

Ademais, inexistiu nos autos qualquer prova no sentido de que tinham as testemunhas a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não cometido, já que os policiais civis sequer o conheciam.

No tocante à alegação de que o acusado é paciente medicinal de maconha, observo que a prescrição médica de págs. 212/219 permite que réu importe o medicamento controlado autorizado pela Anvisa, com base na decisão proferida nos autos da ação civil pública 0090670-16.2014.4.01.3400, não sendo-lhe permitido a sua produção, conforme informação extraída da parte final da ação civil pública 0090670-16.2014.4.01.3400:

ii) procedam, no prazo de 10 (dez) dias, à adequação do art. 61 da Portaria nº

344/98 da ANVISA e à inserção de "ADENDO" ao final da lista E (plantas que podem gerar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) da mesma Portaria, para permitir, por ora, a importação, exclusivamente para fins medicinais, de medicamentos e produtos que possuam como princípios ativos os componentes THC (TETRAHIDROCANNABINOL) e CDB (CANNABIDIOL), mediante apresentação de prescrição médica e assinatura de termo de esclarecimento e responsabilidade pelo paciente ou seu representante legal.

Atendendo à decisão judicial, a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA Nº 66, DE 18 DE MARÇO DE 2016, alterou o art. 61, bem como alterou o art. 3º e revogou os artigos 5º e 6º da RDC 17/2015, passando a permitir a prescrição médica e a importação, por pessoa física, de produtos que contenham as substâncias Canabidiol e THC em sua formulação, exclusivamente para uso próprio e para tratamento de saúde:

"Art. 61 (...) §1º Excetuam-se do disposto no caput: I - a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa que contenham em sua composição a planta Cannabis sp., suas partes ou substâncias obtidas a partir dela, incluindo o tetrahydrocannabinol (THC). II - a prescrição de produtos que possuam as substâncias canabidiol e/ou tetrahydrocannabinol (THC), a serem importados em caráter de excepcionalidade por pessoa física, para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.

Ao que se vê, o acusado não tinha permissão para cultivar plantas e produzir seu próprio medicamento com Canabidiol, muito menos autorização para comercializar e alugar materiais de cultivo de "maconha", pois, como bem salientado pelo réu, tal prática "ainda" é ilegal no Brasil, portanto, é crime.

A alegação da defesa de que o preço para importar tais medicamentos tornaram o tratamento inviável e, "por não ver outra saída", o acusado decidiu, por conta própria, cultivar a planta Cannabis, também não encontra qualquer amparo legal, pois, conforme já exposto acima, ele não tinha qualquer tipo de autorização para produzir seu medicamento, infringindo, portanto, a lei.

Assim, não há como acolher a pretensão de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso próprio, diante desse robusto quadro probatório, considerando que as circunstâncias e a quantidade de entorpecente apreendido são incompatíveis com tal alegação, sendo indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também consumidor, acrescentando-se que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.

O celular e o dinheiro apreendidos estão ontologicamente, no caso concreto, ligados à traficância, razão pela qual de rigor a decretação de seu perdimento, tal como solicitado pelo Promotor de Justiça.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao art. 33 da Lei de Drogas, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes, por disparo de arma de fogo (0037888-80.2007.8.26.0576 - pás. 33), não sendo considerado para fins de cálculo de pena o processo em andamento por tráfico de drogas (1500172-39.2020.8.26.0559 - pág. 34), em razão do Princípio da Presunção de Inocência. Torno a pena definitiva diante da ausência de causas modificadoras nas fases seguintes da dosimetria.

Em relação ao art. 34 da Lei de Drogas, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 1400 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (pág. 33).

Na segunda fase da dosimetria a pena retorna ao mínimo diante da confissão do acusado, o qual confirmou que os objetos encontrados em seu carro se destinavam à produção de "maconha". Na terceira fase nada há a ser considerado.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se que o réu tem maus antecedentes, e vendia maconha gourmet pela internet, dava consultorias a respeito de plantio e cultivo da planta para outros traficantes, além de alugar o equipamento, o que faz afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de

tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, e pelo total de pena aplicada, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão das penas aplicadas e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória, observando que o acusado foi preso em flagrante delito justamente pelo mesmo crime em 28/01/2020 (autos 1500172-39.2020.8.26.0559), ocasião em que lhe fora concedida a liberdade provisória e, ainda assim, o acusado voltou delinquir, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a reiteração criminosa.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado JOÃO GABRIEL MAZZUCATO COSTA, qualificado nos autos e portador do RG 34.162.110, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/2006; e à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 34 da Lei 11.343/2006, penas estas que serão somadas para fim de execução nos termos do art. 69 do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Por fim, decreto o perdimento do aparelho de telefone celular e da quantia apreendida (R\$ 17,00 – págs. 101) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA